

1501509-82.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

## SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501509-82.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000708

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170658/2022 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 2170658 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

LINCOLN OSMAIR FEDRIGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

LINCOLN OSMAIR FEDRIGO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343, porque no dia 23 de junho de 2022, após adquirir de maneira escusa, transportava no interior do seu carro da marca Fiat, modelo Uno Vivace 1.0, ano 2014, na cor branca, placas FTQ0A39, para entrega a consumo de terceiros, mediante venda, a caracterizar a traficância, uma porção de cocaína, na forma de crack, embrulhada em um invólucro plástico envolto por fita adesiva ("tijolo"), pesando 486,230g, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado exerceu o transporte de drogas, sendo "contratado" para levar um "tijolo" de crack até uma favela situada na Via Norte, tarefa para a qual receberia a quantia de R\$ 250,00, sendo que, a fim de não levantar suspeitas da ilícita atividade desempenhada, levou a sua companheira DAIANE CRISTINA SILVA SAAD, que não tinha ciência do conteúdo espúrio do pacote, colocado por ele dentro de uma sacola, também estando no Fiat Uno um dos filhos de tenra idade do casal.

Ocorreu que, ao trafegar pela Rua Tupinambá, esquina com a Rua Rio Negro, o acusado desrespeitou a sinalização de "Pare" ali existente, o que despertou a atenção de policiais militares que estavam pelo local em uma viatura, os quais optaram por segui-lo e abordá-lo logo à frente.

Estacionado o carro, o acusado desembarcou, ao passo que DAIANE disse para os agentes que não poderia fazê-lo, uma vez que estava cuidando de uma criança dentro do veículo, entregando uma sacola que continha restos de alimentos.

Ato contínuo, logo depois que ela desceu do automóvel, os policiais militares localizaram uma segunda sacola, esta sim na qual havia o "tijolo" com quase meio quilo de crack. Também havia dois galões com algo que aparentava ser éter e um pó branco aparentando cafeína, além de uma faca com resquícios de maconha e cocaína. Diante dos fatos, ambos foram levados até a delegacia de polícia, oportunidade em que o acusado confessou a traficância, isentando a companheira que, por sua vez, negou a prática do crime.

Apresentado na audiência de custódia de 24 de junho de 2022, o acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 77/79).

O requerimento de restituição de veículo formulado por Juliano, terceiro interessado (págs. 137/142), ficou indeferido (págs. 158/159).

Pessoalmente notificado (pág. 181), o acusado apresentou resposta à acusação (págs. 156/157) e a denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 22 de agosto de 2022 (pág. 194).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Debates realizados, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A Defesa sustentou ter o acusado confessado a posse dos entorpecentes e as circunstâncias do transporte, sob as considerações de que, não obstante tratar-se de fato típico, teve como cenário de fundo a pandemia do vírus COVID-19, de modo a que a pena, com funções de ressocialização, punição e prevenção, deve ter como medida as particularidades do caso concreto, em atenção à individualização da pena; outrossim, em razão da ausência de titularidade do acusado com o veículo, requereu a devolução ao proprietário.

O representante do terceiro interessado Juliano reiterou a postulação de devolução do veículo formulada às págs. 137/142.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 32/34 e nos exames químicos-toxicológicos acostados a págs. 105/108 e 115/118 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythoxylum coca", na quantidade 486,230g acondicionada em 01 invólucro de plástico incolor envolto por fita adesiva parda (tijolo), da substância cafeína na quantidade de 1.002,06g, bem como detectados vestígios de maconha e cocaína na faca apreendida, conforme laudo pericial de págs. 102/104.

Gustavo Ostanello Alonso, policial militar, recordou que durante patrulhamento pelo bairro Ipiranga deparou-se com o veículo FIAT Uno atravessando bruscamente o sinal de parada obrigatória, a ponto de quase colidir com a viatura policial, razão pela qual, após acompanhamento, dentro do veículo foi visto o acusado na direção, a esposa como passageira e uma menina de dois a três anos no banco detrás sem cadeirinha própria a tanto, o que motivou a abordagem; relatou que, logo ao descer, sem qualquer questionamento prévio, parecendo estar fora de si, nervoso, o acusado prontamente informou não ter habilitação, havia comprado o veículo, mas sem ainda ser concretizada a transferência.

O policial Gustavo narrou, outrossim, que ante a notícia de a esposa não conseguir descer do carro, aproximou-se dela pela porta do passageiro, quando então colocou as sacolas no banco e, ao descer, ela as chutou para debaixo do assento; diante disso, declarou que na vistoria verificou-se haver dentro da sacola quantidade de droga, além de éter e cafeína; complementou que, informalmente, a esposa disse desconhecer o conteúdo da sacola, ao passo que o acusado admitiu transportar o

entorpecente em troca de dinheiro.

Leonardo Ferreira Toledo, também policial militar, a par das informações prestadas por seu parceiro de corporação acima inquirido, reforçou que o acusado desceu nervoso do carro, a esposa somente depois saiu e em uma das sacolas havia porção de crack que exalava forte odor, como também dois galões contendo líquidos destinado ao preparo de drogas; afirmou ter o acusado admitido que ganharia dinheiro no transporte da droga de um bairro para o outro.

Daiane Cristina Silva Saad disse ser companheiro do acusado há doze anos, união da qual têm filhos de três e cinco anos de idade; narrou ter sido convidada pelo acusado para comer lanche e ao ir sozinha realizar o pagamento viu o acusado em conversas com um rapaz de moto, de quem houve a transferência de uma sacola; relatou que, na sequência, retornaram para o carro e, no trajeto para casa, ao cruzarem com viatura policial, o acusado alertou estar com a sacola e, por estar errado, decidiu parar o veículo, jogou a sacola sob seus pés (de Daiane), quando então os policiais se aproximaram e o acusado disse em voz alta “caiu a casa”. Daiane mencionou que aos policiais explicou haver sacolas com o restante de lanches e a sacola do acusado, dentro da qual, na vistoria, a equipe constatou a presença de entorpecente; informou que o acusado pediu o carro a Juliano para levar no mecânico e, oportunamente, combinarem tanto sobre a locação por R\$900,00, pois pretendia o acusado trabalhar de motorista de Uber para, mais adiante, negociar eventual aquisição propriamente dita do veículo; afirmou ser o acusado habilitado para carro e moto, mas antes só tinha a moto em seu próprio nome.

Jeane de Faria Silverio, proprietária de food truck, declarou que o acusado trabalhou por aproximadamente um ano na função de entregador, com o uso de moto própria, e a ele pagava o valor de cinquenta reais de diária, sem prejuízo das comissões das entregas noturnas; comentou que, na data dos fatos, entre às 21h30m e 22h, o acusado, com carro que nunca o viu dirigir antes, foi até à lanchonete com a esposa e a filha para comerem lanche.

Interrogado, o acusado alegou ao tomar conhecimento do anúncio de venda do veículo promovido por Juliano foi ao encontro dele solicitar a possibilidade de locar o carro e, na terça-feira, pegou-o para levar no mecânico, sem antecipar nenhum valor; como ainda não o havia restituído, no sábado Juliano compareceu para cobrar notícias e a esposa informou a ele sobre a prisão e a apreensão do veículo.

O acusado mencionou que um rapaz de nome Tiago fez a oferta de transporte de líquidos inflamáveis e, para tanto, orientado por ele a ir até à lanchonete e pedir lanche, lá surgiu um rapaz de moto e dele recebeu a sacola, guardou-a no carro e, no trajeto, percorridos de cinco a seis quarteirões, cruzou com os policiais que, em atendimento à ordem emanada, logo parou, desceu esclarecendo haver líquidos inflamáveis dentro do carro que, às pressas da situação ali ocorrida, acabou posicionando-os sob as pernas de sua esposa; completou que, por R\$250,00, transportaria os líquidos sabendo-os da ilicitude; alegou desconhecer sobre a eventual existência de compartimento secreto no veículo.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

Mesmo porque confessou a dinâmica delineada nos testemunhos, a representar harmonia descritiva que se coaduna na exata medida que os fatos ocorreram.

O caso concreto não há de ser compreendido como hipótese de ausência de dolo ou de erro de tipo, na medida em que o acusado, ao ser interrogado, deu detalhes que não condizem, por mais pueril que se admita, com situação de imprevisibilidade do conteúdo do material transportado, tudo para fins de transporte, em troca de duzentos e cinquenta reais.

E ainda que imaginasse serem apenas líquidos inflamáveis, ao avistar a viatura policial, segundo confirmou sua esposa, disse estar transportando conteúdo ilícito e até mesmo lançou a sacola sob os pés de Daiane, logo dizendo “caiu a casa”.

As declarações outrora prestadas em fase extrajudicial reforçam a exata compreensão sobre a existência dos entorpecentes, ao lá o acusado relatar, na presença de advogado, “pegou uma sacola que estava em seus pés, com produto entorpecente, jogando-a nos pés de sua amásia, logo foram abordados pelos policiais militares os quais localizaram a sacola e a substância entorpecente” (pág. 6).

Por sua vez, a esposa Daiane, também acompanhada de advogado, fez a consideração de que "acreditava que seu amásio havia parado de mexer com essas "porcarias", que inclusive pediu isso a ele" (pág. 7).

Mesmo que comprovada a existência e envolvimento da terceira pessoa no fornecimento da sacola, ainda assim a vinculação imediata do acusado com os entorpecentes encontrar-se-ia estampada nas circunstâncias gerais que conduziram tanto à aparição da equipe policial no local, como em seu comportamento que logo dali foi notado. Para a consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792); "No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); "Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela quantidade, variedade, natureza e forma de acondicionamento, divididos em porções individuais, pela detalhada informação apócrifa, cuja veracidade foi constatada pelos agentes públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva, não remanescendo quaisquer dúvidas, quanto ao destino a terceiros, salientando-se que eventual condição de usuária não seria impeditiva da realização concomitante do comércio clandestino, o que arreda a tese desclassificatória ventilada em autodefesa." (TJ-SP; APL 0001364-89.2016.8.26.0537; Ac. 10947155; São Bernardo do Campo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2794).

Destarte, os elementos reunidos em todo o percurso da instrução probatória confirmam que a destinação dos entorpecentes seria para terceiras pessoas, pois em condições próprias a tanto de armazenamento, de embalagem, fracionamento, acompanhados de cafeína que, segundo o laudo pericial de pág. 117, "consta na Lista "III" - Fármacos, adulterantes e diluentes capazes de serem empregados na preparação de drogas, sujeitos a controle e fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro, em qualquer concentração. - da portaria MJSP 240/19".

Caracterizado o crime de tráfico de drogas, passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis as consequências do crime, ante a expressiva quantidade de 486,230g de cocaína, na forma de crack, acompanhada de 1.002,06g de cafeína como meio empregado na preparação circunstâncias indicativas das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição da droga. Nesse sentido: "1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2.

Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 2 anos de reclusão com fundamento na natureza, na variedade e na quantidade dos entorpecentes apreendidos - 1 porção de crack (988,41g) e 4 porções de cocaína (1.543,03g) -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), e a preponderância de tais circunstâncias conforme estabelece o art. 42 da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 553.106/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 19/05/2020), justificando o aumento de dez meses de reclusão e oitenta dias-multa. Assim, relembrada a variação de pena privativa de liberdade de cinco a quinze anos de reclusão, cumpre estabelecer a pena-base em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta dias-multa;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a dupla reincidência (Processo nº 0025863-41.2013.8.26.0506 - 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP com pena Extinta em 19/02/2019, pág. 63; e Processo nº 0003070-24.2016.8.26.0597 - 1ª Vara Criminal de Sertãozinho/SP em cumprimento de pena, pág. 64), cada uma a importar o aumento de dez meses e oitenta dias-multa, representando, no conjunto, a elevação de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta dias-multa, com o alcance do subtotal de sete anos e seis meses de reclusão e setecentos e quarenta dias-multa; por outro lado, ante a confissão prestada nos moldes da súmula nº 545, do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a redução de dez meses de reclusão e oitenta dias-multa, a perfazer o subtotal de seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta dias-multa;

Neste particular, importante observar que no REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, houve a readequação da tese estabelecida no tema repetitivo nº 585, para firmar que “nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”; III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressaltando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, porque duplamente reincidente, conforme anotado no item “II” acima. Torno definitivo o quantum de seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, consideradas a circunstância judicial desfavorável e a dupla reincidência, conforme anotado nos itens “I” e “II”, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem ainda a hediondez, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento. Insuficiente o critério objetivo temporal para progressão para o regime semiaberto (artigo 387, parágrafo 2º, do Código Processo Penal), iniciará o cumprimento no regime original. Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência condeno LINCOLN OSMAIR FEDRIGO, qualificado nos autos, à pena de seis anos e oito meses de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de seiscentos e sessenta dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas.

Em virtude da circunstância judicial desfavorável e da dupla reincidência, bem como da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 77/79), sobretudo agora por estar emoldurada a condenação ao caput, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ou seja, revestida de natureza hedionda, aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com o elevado montante da pena e regime prisional imposto a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de

interposição de recurso, extraia-se guia de execução provisória.

Em atenção ao item "2" de pág. 123, porque inservível para outros fins e inexpressiva economicamente, comunique-se a autoridade policial para promover a destruição da faca apreendida.

Para o veículo apreendido, importante considerar que o Supremo Tribunal Federal, por seu órgão pleno, ao apreciar o tema 647 de Repercussão Geral (RE 638491) definiu como tese "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal".

A controvérsia instalada sobre a posse do veículo fica dirimida pelos contornos gerais produzidos na prova oral e naquela fala inaugural prestada pelo acusado (pág. 6) perante a autoridade policial, quando mencionou ser seu o veículo usado para o transporte da droga, embora apenas não estivesse registrado em seu nome (diante da ainda não quitação do preço), não servindo a eventual suposta locação para estabelecer compreensão contrária, seja diante da falta de verossimilhança de que, sem antecipação de nenhum valor, o acusado manteve-se por quase vários dias na posse do veículo, sem qualquer resistência do apontado locador/vendedor, seja porque, como é sabido, "a transferência da propriedade do veículo ocorre por meio da tradição, impondo-se o registro no órgão de trânsito como requisito tão somente para fins de publicidade" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.837.583/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021), conforme já registrado na decisão de págs.158/159.

Por tais fundamentos e diante do disposto no artigo 63 da Lei de Drogas, decreto o perdimento do veículo apreendido em favor da União.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA